

1500515-41.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... à conduta do acusado para a prática do tráfico, mas não seria gerente como ele. Aliás, não tem outros envolvimento com o tráfico. Assim, deve ser beneficiada com a causa de diminuição do tráfico privilegiado, podendo ser beneficiada com o regime aberto. Por fim, uma vez que comprovado que o dinheiro apreendido era oriundo do comércio de drogas, o Órgão Ministerial ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500515-41.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2098082/2022 -

DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 24202789 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2098082 - 05º

D.P. PIRACICABA, 2098082/2022 - 05º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JACKSON LUIDH ORTIZ DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Contr. nº 2022/000420

Aos 26 de setembro de 2022, às 15:30 horas, por meio de audiência virtual realizada pelo aplicativo Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e 208/22 e em observância ao Provimento CSM 2651/2022 e a Resolução 850/21, da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). Antonio Carlos Perez Antunes da Silva, foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presente o réu JACKSON LUIDH ORTIZ DOS SANTOS e MONIQUE ALZIRA GALDINO EVANGELISTA FERREIRA (ambos presos).

Presente a Defensoria Pública na pessoa do Dr. Marcelo Dayrell Vivas e Defensora Dra. Ana Paula de Moura Pimenta.

Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: PM Junior Cesar Rodrigues e PM Rafael Pereira da Silva.

Ausente a testemunha de defesa: Juliana Guilherme.

Presente a testemunha de defesa: Angelica Teodora do Espirito Santo da Silva (mas não foi ouvida, pois a defesa desistiu).

Antes do início da audiência foi (foram) realizada(s) fotografia(s) do(s) documento(s) de identificação exibidos pela(s) testemunha(s), o que foi aceito pelas partes, (imagem(ns) exibida(s) durante audiência).

INICIADOS OS TRABALHOS, foi assegurada à defesa oportunidade para entrevista reservada com o(a) acusad(a) e todos os presentes foram retirados da sala,

inclusive a M.M. Juíza, seu(sua) assistente e o Promotor de Justiça, de modo a não terem acesso a conversa privada entre o(a) ré(u) e sua defesa.

Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Após a identificação pessoal, através de exibição à câmera de documento original com foto, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s), primeiramente a de acusação (PM Rafael) e, em seguida, o interrogatório dos réus foi captado e gravado em áudio e vídeo.

Dada a palavra ao Dr. Promotor e as Defesas, por eles foi dito que desistiam da testemunha comum PM JÚNIOR e das testemunhas de defesa JULIANA e ANGELICA, o que foi homologado pelo(a) MM. Juiz(a).

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências.

Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido.

Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). JACKSON LUIDHORTIZ DOS SANTOS e MONIQUE ALZIRA GALDINO EVANGELISTA FERREIRA, estão sendo processados como incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pois no dia 09 de abril de 2022, às 11:40 horas, na Rua Amêndoa, nº 44, Bairro Vila Sônia, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, previamente ajustados, tinham em depósito, para fins de tráfico, respectivamente, 63,0g de cocaína, distribuídos em 377 eppendorfs, 42,2g de Cannabis sativa L., distribuídos em 120 invólucros, 95,3g de cocaína na forma de pedra, distribuídos em 01 invólucro, e 888,9g de Cannabis sativa L., distribuídos em 279 invólucros, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (fls. 96/99). Os réus foram notificados, a denúncia foi recebida e durante a instrução prestaram depoimento as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, os réus interrogados. A ação penal deve ser julgada procedente. Em seu interrogatório, o réu Jacson negou a prática delitiva, mas disse que era realmente de Sorocaba e estava há um mês em Piracicaba. Disse que estava em gozo de liberdade provisória por tráfico e que naquela cidade foram apreendidos 8 kg de maconha. Monique negou também a prática delitiva e disse que a droga não era sua e que provavelmente era de Jacson. Ele indicou onde as drogas estavam e permitiu a entrada dos policiais militares. A materialidade delitiva foi confirmada nos autos pelo auto de exibição e apreensão a fls. 28/29, foto a fls. 37/38 e laudo pericial a fls. 108/111. Da mesma forma, comprovada a autoria delitiva. De fato, o policial relatou, na fase informativa (fls. 07), que "estavam em patrulhamento de rotina pelo Bairro Javari, quando a equipe policial foi solicitada por um transeunte que não quis se identificar com medo de represaria do tráfico, onde esta pessoa informou para os policiais que um casal teria vindo da cidade de Sorocaba, e estariam armazenando uma grande quantidade de drogas em uma residência que fica na Rua Amêndoa, 88, casa 4, no mesmo bairro, sendo que este informante alegou para os policiais que este casal seria responsável pela distribuição de drogas no bairro. Diante desta informação e em busca da verdade, os policiais foram até o local informado e quando chegaram na residência, os policiais foram recepcionados por um indivíduo de nome JACSON LUIDH ORTIS DOSSANTOS, onde este foi informado pelos policiais a respeito da denúncia, que de pronto JACSON confessou que teria drogas na residência. JACSON autorizou expressamente a entrada dos policiais e ainda apontou para os policiais onde estaria a droga escondida. Os policiais localizaram, onde JACSON apontou, debaixo da pia da cozinha uma mala, que em seu interior havia uma grande quantidade de drogas, sendo 154 micro tubos de cor amarelo aparentando ser COCAÍNA, 223 micro tubos de cor branca também com COCAÍNA, 274 porções de MACONHA, 5 tabletes pequenos também de MACONHA, 120 recipientes pequenos de cor vermelhos com substância aparentando ser MACONHA (tipo SKANK), 1 pedra grande em forma bruta de CRACK, uma balança de precisão, 2 celulares e ainda o valor de \$ 100,00 reais. Esclarece o policial que dentro da residência, conforme a denúncia, também havia uma mulher que foi identificada por MONIQUE ALZIRA GALDINO EVANGELISTA FERREIRA.

Indagados informalmente pelos policiais, JACSON alegou que a droga tinha vindo da cidade de Sorocaba e que ele seria o responsável pelo armazenamento e distribuição desta drogas. Por sua vez, MONIQUE alegou ser amasia de JACSON, que tinha ciência que o mesmo traficava drogas e dentro da residência do casal armazenavam drogas e depois distribuíam." Em juízo confirmou sua versão. Acrescentou que pelas informações recebidas, pela quantidade de drogas, pelo fato das drogas virem de Sorocaba e se destinarem à distribuição nesta cidade, concluiu que ele ocupava um cargo alto na organização da venda de entorpecentes, como gerente. Informou que uma parte de entorpecentes era de Skank, que é uma parte nobre da maconha e que tem em razão disso valor econômico mais alto. Falou que ambos confessaram informalmente que os entorpecentes eram originários de Sorocaba e se destinavam à distribuição nesta cidade. Assim, a grande quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, juntamente com a apreensão de dinheiro, somadas às circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam o comércio ilícito. De fato, havia informações de que os acusados fariam a distribuição de grande quantidade de drogas nesta cidade, originárias de Sorocaba. Ademais, no local foram encontrados os entorpecentes, bem como dinheiro e balança de precisão. Ainda, não somente foi apreendida grande quantidade de drogas, como, também, parte, de alto valor comercial, qual seja, Skank. Outrossim, os réus informalmente confessaram a prática delitiva. Neste panorama, devidamente demonstrados os fatos descritos na inicial. Diante do acima exposto, requer-se a procedência da ação, condenando-se os réus nos termos da incoativa. Na aplicação da pena há que se observar que os acusados não ostentam antecedentes (certidões a fls. 55/56, 60/61), mas Jackson foi preso em flagrante anteriormente pela prática de tráfico e estava em liberdade provisória (cerca de 8 kg de maconha, como ele informou nesta data em seu interrogatório). Ademais, também em virtude da grande quantidade e variedade de drogas apreendida, restou claro que ele se dedica a atividades criminosas e era certamente um dos gerentes do tráfico no local e não faz jus à causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. Outrossim, o regime inicial de cumprimento de pena do réu deverá ser o fechado, de acordo com as normas legais, e porque o crime de tráfico merece um grau maior de reprovabilidade, pois causa sérias consequências no meio social, notadamente no meio familiar, fomentando o uso indiscriminado de entorpecentes e, conseqüentemente, a prática de outros crimes pelo usuário, como pequenos furtos e roubos, os quais são praticados com o escopo de sustentar o seu vício. Incabível, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que reconhecida a impossibilidade de ser aplicado o redutor pelas razões antes mencionadas, a pena suplantará 04 anos, bem como o crime em questão é de elevada gravidade, o que demonstra não ser a medida socialmente adequada. Já em relação a Monique, entendo que as informações dos autos dão conta de que aderiu à conduta do acusado para a prática do tráfico, mas não seria gerente como ele. Aliás, não tem outros envolvimento com o tráfico. Assim, deve ser beneficiada com a causa de diminuição do tráfico privilegiado, podendo ser beneficiada com o regime aberto. Por fim, uma vez que comprovado que o dinheiro apreendido era oriundo do comércio de drogas, o Órgão Ministerial requer que seja decretada sua perda.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a) do réu JACKSON, foi dito o seguinte: MM. Juíza. JACKSON LUIDH ORTIZ DOS SANTOS foi denunciado como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em razão de fatos supostamente ocorridos no 09 de abril de 2022, às 11:40 horas, na Rua Amêndoa, nº 44, Bairro Vila Sônia, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, qualificado a fls. 14, e MONIQUE ALZIRAGALDINO EVANGELISTA FERREIRA, qualificada a fls. 11, previamente ajustados, tinham em depósito, para fins de tráfico, respectivamente, 63,0g de cocaína, distribuídos em 377 pendorfs, 42,2g de Cannabis sativa L., distribuídos em 120 invólucros, 95,3g de cocaína na forma de pedra, distribuídos em 01 invólucro, e 888,9g de Cannabis sativa L., distribuído em 279 invólucros, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Encerrada a instrução, o Ministério Público postulou pela condenação. 2. ABSOLVIÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE PROVAS O caso é de absolvição em razão da insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII), eis que deficitários os elementos

de prova. De fato, a condenação estaria embasada apenas nos relatos de um policial militar. Nesse contexto, não se pode deixar de levar em consideração que os policiais estão intimamente ligados ao fato criminoso, sendo manifestamente tendencioso o seu depoimento, já que tendentes a ratificar a sua atuação pré-processual e, eventualmente, encobrir qualquer tipo de irregularidade nela presente. Com efeito, os relatos oferecidos pelos agentes de segurança pública, contrariamente ao que ocorre com os demais cidadãos, não são dotados da necessária imparcialidade, na medida em que eles tenderão, por certo, a corroborar as diligências (e a própria prisão) efetivadas na fase extraprocessual, sendo naturalmente inclinados, portanto, a atestar a lisura das suas ações realizadas na fase investigativa. Por isso, em razão do princípio da interest disqualification, tais agentes não deveriam ser admitidos a prestar declarações. A esse propósito: “[...] é a partir do momento em que o júri deixa de decidir com base em conhecimento próprios, para servir-se de provas, fornecidas principalmente por testemunhas, que se inicia a formação de um conjunto de regras de exclusão (exclusionary rules), cuja finalidade é a de controlar a qualidade das provas apresentadas aos jurados, evitando que esses leigos pudessem ser induzidos a erros de apreciação. Dentre tais regras, sobressaem a rule against hearsay, destinada a evitar que o júri tenha contado com um testemunho de segunda mão, e o princípio da interest disqualification, segundo o qual não são admissíveis testemunhas que possam ter interesse na solução da causa [...]” (GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 37-38). Apesar disso, firmou-se uma posição intermediária, ou seja, fixou-se o entendimento de que os depoimentos dos agentes de segurança pública, sem o amparo de outras provas que estejam ao alcance dos órgãos responsáveis pela persecução penal, não podem embasar uma sentença condenatória, sob pena de se atribuir ao referido elemento de prova caráter quase absoluto no processo penal, fragilizando-se as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, bem como inviabilizando a própria descoberta da verdade dos fatos. Na doutrina: “Quanto ao testemunho dos policiais, há correntes radicais, que, pelo seu próprio extremismo, devem ser descartadas. [...]. Deve prevalecer uma posição intermediária: se os policiais não podem ser considerados suspeitos, pelo simples fato de serem policiais, por outro lado, é inegável que o seu interesse na demonstração da legalidade de sua atuação nos atos investigatórios praticados, pelo que seus depoimentos têm valor relativo, devendo ser cotejados com outros elementos de provas existentes nos autos, em especial o testemunho de outras pessoas estranhas aos quadros da polícia. Não se pode esquecer que as testemunhas são, por definição, terceiros imparciais, sem qualquer interesse no processo, o que não é exatamente o caso dos policiais em relação aos crimes por eles investigados. Por tais motivos, não se deve admitir que seja proferida uma sentença condenatória com base exclusiva no depoimento de policiais, ainda que estes se mostrem harmônicos entre si” (Processo penal. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 492-493). No mesmo sentido: “Logicamente, [os Policiais] jamais descreveriam nos registros policiais que agiram utilizando violência ou algum procedimento ilegal. Por terem participado da ação, sua versão precisaria ser recepcionada com reservas. [...]. Não há impedimentos aos testemunhos de policiais, mas por terem participado da prisão, seria importante que suas palavras fossem recebidas com certa reserva, já que seus relatos poderiam ter o objetivo de imprimir uma legalidade e legitimidade de sua própria atuação” (JESUS, Maria Gorete Marques de. A verdade jurídica nos processos de tráfico de drogas. Belo Horizonte: D’Plácido, 2018, p. 248). Nessa linha de raciocínio, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo que os testemunhos dos Policiais responsáveis pela realização do flagrante não são isentos e, por isso, devem ser corroborados por outros elementos de prova. Isso porque “Os policiais militares investigadores do fato, como verdadeiros assistentes da parte autora, não têm, sozinhos, em face da própria condição de servirem como longa manus do Ministério Público, enquanto ditam as provas, a isenção suficiente para demarcarem, através de seus exclusivos depoimentos, um justo e razoável juízo de reprovação penal”. Logo, “Admitir-se entendimento outro é o mesmo que fazer ouvidos moucos ao som do retumbante princípio da proporcionalidade, desequilibrando, a não mais bastar, as

atuações dos atores processuais, em manifesto e desmesurado prejuízo à ampla defesa do acusado, tornando-o sempre a parte vulnerável da ação penal, com mínimas chances, para não se dizer nenhuma, de se ver livre da imputação" (TJ-SP, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0373088-52.2010.8.26.0000, Relator Sydnei de Oliveira Jr, p. 8 do voto do Relator). É imperioso, por isso, que a condenação não seja proferida apenas com embasamento nas declarações dos policiais. Aliás, no que se refere à Polícia Militar, o Procedimento Operacional Padrão estabelecido em 11/4/2006 determina aos policiais que reúnam dados e testemunhas da ocorrência. Não se pode, assim, admitir que a condenação seja proferida apenas com base em depoimentos policiais. Ora, "Se a polícia militar ou a polícia civil têm agido na repressão ao tráfico de drogas, a ação de colheita de provas não pode ser viciada pelo intento repressivo. Em outras palavras, a polícia judiciária na sua atividade de colheita de provas deve estar subordinada aos mesmos princípios de todos os participantes da relação processual, ou seja, deve estar vinculada à necessidade de busca da verdade, não podendo deixar a repressão de que está imbuída prejudicar a imparcialidade necessária. Por isso defendeu-se a impossibilidade de se trazer apenas testemunhas policiais para o flagrante, formando completamente o conteúdo probatório testemunhal do futuro processo, porque depois é praticamente impossível para a defesa encontrar outras pessoas envolvidas com a conduta que possam trazer aspectos positivos e favoráveis ao réu, sendo obrigação da polícia encontrar testemunhas o mais isentas possíveis no momento do fato, atitude que poderia vir a favor não só dá defesa, mas da credibilidade do processo como um todo" (VALOIS, Luís Carlos. O direito penal da guerra às drogas. 3. ed. Belo Horizonte: D'Plácido, 2019, p. 516, grifos nossos). Portanto, as declarações dos agentes de segurança pública devem ser apreciadas com cautela e corroboradas por outros elementos de prova, sob pena de se desnaturar o próprio processo penal. De fato, em tal situação, "O processo, que era para ser o momento de verificar a existência do fato, torna-se um momento de verificar a repetição do que foi escrito pela polícia, o que não é a mesma coisa" (VALOIS, Luís Carlos. O direito penal da guerra às drogas. 3. ed. Belo Horizonte: D'Plácido, 2019, p. 519). Isso posto, sendo deficitário o conjunto probatório, não superado o standard probatório da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) – conclusão sobre a responsabilidade além de qualquer dúvida razoável – a absolvição é medida que se impõe (CPP, art. 386, VII).

3. DAS TESES SUBSIDIÁRIAS 3.1. Da dosimetria de pena. No entanto, caso se entenda pela condenação, é certo que, em relação à dosimetria de pena, na primeira fase, a pena-base deverá ser fixada no patamar mínimo legal. De fato, o dolo é inerente à figura típica e as consequências são normais para casos similares, assim como os motivos para a prática do crime, não justificando uma exasperação na primeira fase. Ademais, o acusado é tecnicamente primário, circunstância que deve ser apreciada na segunda etapa de dosimetria de pena. Sob outro prisma, no que se refere à quantidade de drogas, não há justificativa para o aumento da pena-base com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas. Isso porque o aumento da pena-base com fundamento no disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 exige que a quantidade de drogas seja expressiva, conforme jurisprudência do TJ-SP e do STJ (TJ-SP, 2ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 0003146-82.2017.8.26.0542 Rel. Des. Francisco Orlando, julgado em 10/6/2019. & AgRg no HC 465.898/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018), não sendo este o caso dos presentes autos. Sendo assim, a pena-base deve permanecer no patamar mínimo legal. Na segunda etapa da dosimetria da pena, que seja levada em consideração a atenuante da primariedade, uma vez que o indivíduo é tecnicamente primário, respondendo por uma única ação em andamento, o que não equivale a uma condenação. Não podendo ser usada em seu desfavor a fim de elevação da pena. Na terceira etapa de dosimetria de pena, deverá ser aplicado o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Isso porque o imputado preencheu todos os requisitos exigidos pelo referido dispositivo legal: (a) ele é primário, (b) possui bons antecedentes, (c) não há prova de que integre organização criminosa ou (d) que se dedique a atividades criminosas. A afirmação de que o sentenciado se dedica a atividades criminosas não vem corroborada por nenhuma condenação anterior, qualquer

investigação ou qualquer prova juntada aos autos, se tratando de mera opinião pessoal de um policial que encontrou sustentação na manifestação do Ministério Público. Sob outro prisma, no que se refere à quantidade e natureza das drogas apreendidas em seu poder, impõe-se destacar que se tratam-se de circunstâncias do crime (CP, art. 59 e LD, art. 42) e, dessa forma, não podem ser valoradas para sopesar o quantum de diminuição da pena ou a denegação de sua aplicação, sob pena de vulneração ao princípio da proibição do bis in idem (CADH, art. 8.2.h). Por isso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sede de repercussão geral, que a natureza e a quantidade de entorpecentes somente podem ser valoradas em uma das etapas da dosimetria: ARE 666334 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-084 DIVULG 05-05-2014 PUBLIC 06-05-2014. A decisão do Supremo Tribunal Federal impõe-se a todo o Judiciário, tendo em vista que firmada em âmbito de repercussão geral, não podendo deixar de ser observada (CPC, art. 927 c. c/ art. 1.039). Aliás, trata-se de entendimento irreparável: o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 permitiu que a natureza e a quantidade de drogas fossem utilizadas, única e exclusivamente, para fins de aumento da pena-base, isto é, autorizou a sua utilização como circunstâncias judiciais, de modo que a sua utilização para fins diversos viola, inquestionavelmente, o princípio da legalidade. Por isso, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a quantidade e a natureza dos entorpecentes não autorizam a automática conclusão de que o imputado tenha envolvimento com crime organizado ou prática reiteradamente o crime de tráfico de drogas, não se podendo utilizar tal argumentação para denegar a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. É o que se infere do seguinte precedente, em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu o tráfico privilegiado a indivíduo preso em flagrante por portar 132,85Kg de maconha: RHC 138715, Relator(a):& Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 08-06-2017 PUBLIC 09-06-2017. No mesmo sentido, confira-se, ainda, o seguinte precedente: HC 195319 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 04-03-2021 PUBLIC 05-03-2021; AgRg no AREsp 1807566/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021. Sendo assim, deve ser aplicado o disposto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. E, no que se refere ao patamar de redução, impõe-se registrar que, em recente decisão (HC 106.135), a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal frisou que a quantidade de pena para condenado por tráfico não está diretamente relacionada com a quantidade de droga encontrada. Na decisão, destacou-se que a quantidade de droga deve ser considerada na primeira fase da individualização da pena, sendo impróprio invocá-la devido à escolha do fator de redução prevista na Lei de Drogas, sob pena de bis in idem, proibido expressamente pelo art. 8.4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e pela Constituição Federal, art. 5º, XXXVI – duas penas sobre um mesmo fato gerador. Além disso, salientou o Supremo Tribunal Federal que, presentes os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, o redutor deve ser aplicado em sua totalidade (2/3). Nesse contexto, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, infere-se que a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em critério inferior a 2/3, somente se justifica quando a quantidade de drogas seja exacerbada, o que não é o caso dos autos: HC 136651, Relator(a):& Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão:& Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 01-08-2017 PUBLIC 02-08-2017; RHC 132860, Relator(a):& Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 19/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 27-05-2016 PUBLIC 30-05-2016. Na mesma linha, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça, frisou que “[...] à falta de parâmetros idôneos que justifiquem o maior rigor punitivo, notadamente diante da primariedade do recorrente, tem-se por considerar inidônea a aplicação do redutor em fração diversa da máxima permitida [...]” (STJ, Recurso Especial n. 1.815.172-SP, Rel. Min. Sebastião Rei Júnior, julgado em 1º/8/2019). Ou seja, presentes os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a incidência do redutor é impositiva, devendo a diminuição operar-se no seu patamar máximo, porquanto a legislação não expressa critérios que permitam dinamizar o grau de redução. Diante do exposto, deverá ser

reconhecida a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, devendo ser aplicada em seu máximo patamar. 3.2. Do regime inicial de cumprimento de pena. Possibilidade de fixação do regime inicial diverso do fechado. Aplicação do art. 387, § 2º, do CPP. Como sabido, o regime inicial deve ser fixado em estrita observância do art. 33 do Código Penal e, caso se entenda pela fixação de regime mais gravoso, a motivação deve dar-se de modo concreto, conforme se infere das Súmulas 718 e 719, do Supremo Tribunal Federal, e Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça, sendo vedado apelar à gravidade em abstrato do delito para a fixação do regime inicial de pena. Além disso, em casos de tráfico de drogas, não poderá o regime ser definido com embasamento apenas no disposto no art. 2º, § 1º, da Lei dos Crimes Hediondos, tendo em vista que sua inconstitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF, HC 111840/ES, rel. Min. Dias Toffoli, 27.6.2012). Isso posto, deverá ser fixado o regime inicial aberto, ou, subsidiariamente, o semiaberto. Perante o exposto, pugna-se: a) pela absolvição (CPP, art. 386, VII); b) subsidiariamente: b.1) no que se refere à dosimetria de pena, (i) seja fixada a pena-base no patamar mínimo legal, (ii) seja reconhecida a atenuante da primariedade técnica; b.2) seja reconhecido o tráfico privilegiado; c) por fim, seja o réu reconhecido como beneficiário do direito à gratuidade de justiça, suspendendo-se a exigibilidade da condenação em custas (CPC, art. 98, § 3º, c. c/ art. 3º do CPP).

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a) da ré MONIQUE, foram apresentadas alegações finais oralmente, devidamente gravadas por meio audiovisual.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos,

JACKSON LUIDH ORTIZ DOS SANTOS e MONIQUE ALZIRA GALDINO EVANGELISTA FERREIRA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 09 de abril de 2022, às 11h40min, na Rua Amêndoa nº 44, Bairro Vila Sônia, nesta cidade e Comarca, tinham em depósito, para fins de tráfico, 63,0g de cocaína, distribuídos em 377 "ependorfs", 42,2g de "Cannabis sativa L", distribuídos em 120 invólucros, 95,3g de cocaína na forma de pedra, distribuídos em 01 invólucro, e 888,9g de "Cannabis sativa L.", distribuídos em 279 invólucros, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que policiais militares estavam em patrulhamento e receberam informações de que um casal estaria praticando o tráfico de drogas no local acima mencionado. Em razão disso, para lá se dirigiram e, de fato, encontraram os acusados em tal endereço. Em seguida, realizaram buscas no interior do referido imóvel e localizaram as drogas acima descritas, uma balança de precisão e a quantia de R\$100,00, oriunda do narcotráfico.

Narra, por fim, que todas as drogas apreendidas pertenciam aos acusados e se destinavam ao narcotráfico.

Os réus foram notificados nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (Jackson fls. 122 e Monique fls. 157). Defesa preliminar do réu Jackson apresentada às fls. 153/154 e da ré Monique às fls. 161/168. Após, a denúncia foi recebida (fls. 177/178) e os réus foram citados (Jackson às fls. 224 e Monique às fls. 222).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha arrolada em comum pela acusação e defesa do réu Jackson. Ao final, os réus foram interrogados.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autorias e materialidade do delito.

As Defesas pediram a absolvição, sustentando que as provas dos autos não demonstraram a prática do crime de tráfico de drogas pelos acusados.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede.

A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes elementos:

- 1) Boletim de ocorrência de fls. 21/27;
- 2) Auto de exibição e apreensão de fls. 28/29 e fotografias de fls. 37/38;

3) Auto de constatação preliminar de fls. 33/36 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 108/111, com resultados positivos para cocaína e THC em relação às substâncias apreendidas.

A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 14/16), o réu negou o crime. Disse que não morava naquela casa e que a droga apreendida pertencia ao dono imóvel, conhecido por Borges.

Alegou que veio para esta cidade em busca de emprego e Borges o deixou ficar na sua casa. Não sabia que ali havia drogas. Afirmou que autorizou a entrada dos policiais no imóvel, os quais foram até lá devido a uma denúncia de briga de casal.

Interrogado em juízo (gravação), Jackson novamente negou o crime. Alegou que veio de Sorocaba para Piracicaba atrás de emprego. Estava morando aqui há um mês aproximadamente. Alguns dias antes dos fatos, a corré, sua namorada, veio para cá também e estavam morando juntos no cômodo da frente do imóvel indicado na denúncia, uma kitnet composta de dois cômodos. Naquele imóvel, moravam várias outras pessoas. Alugou a moradia de Borges. No dia dos fatos, os policiais chegaram ali de manhã perguntando se tinha ocorrido alguma briga de casal. Negou o fato para eles. Eles, então, perguntaram se havia droga lá, pois havia denúncia de tráfico de entorpecentes no local. Disse que não tinha e permitiu que entrassem no imóvel para realizarem uma busca. Afirmou que arrombaram a porta do outro cômodo, que servia de cozinha, e que era ocupado por Borges e ali encontraram as drogas apreendidas. Disse que já foi preso por tráfico de drogas em Sorocaba, com 12 quilos de maconha. Não conhecia os policiais anteriormente. Negou ser usuário de drogas, dizendo que Monique também não usava entorpecentes.

A ré, por sua vez, ouvida na fase informativa (fls. 11/13), declarou que não sabia da existência de drogas na residência, alegando que não morava lá, mas sim na cidade de Sorocaba. Disse que Jackson era seu namorado e vieram para esta cidade atrás de trabalho e fazia três dias que estavam ali. Afirmou que não conhecia o dono da casa, que era um amigo de Jackson, de nome Davi. Por fim, afirmou ter visto os policiais encontrarem as drogas na cozinha.

Interrogada em juízo (gravação), a ré novamente negou o crime, mas também alterou em parte a versão dos fatos. Disse que poucos dias antes da ocorrência, veio para Piracicaba morar com Jackson, seu namorado, com quem havia se reconciliado. Estavam residindo no imóvel indicado na denúncia, onde só moravam os dois. Disse que Jackson autorizou o ingresso dos policiais no imóvel e indicou a eles onde estavam guardados os entorpecentes apreendidos, os quais provavelmente lhe pertenciam. Disse desconhecer sua existência no imóvel, bem assim que Jackson estivesse traficando. Afirmou acreditar que a mala onde estavam as drogas tratava-se de uma mala de ferramentas.

As negativas foram afastadas pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase informativa (fls. 07/08) e em juízo (gravação), o policial militar Júnior César Rodrigues declarou que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento de rotina pelo Bairro Javari quando foram solicitados por um transeunte que não quis se identificar com medo de represália, o qual informou que um casal tinha vindo da cidade de Sorocaba e estaria armazenando, para distribuição no bairro, grande quantidade de drogas em uma residência que ficava na Rua Amêndoa nº 88, casa 04. Diante disso, dirigiram-se ao local dos fatos, onde havia várias casas iguais e quando bateram palmas na casa de número 04, foram recebidos por Jackson. Assim que ele abriu a porta, já viram que não havia móveis na cozinha, o que lhes causou estranheza. Informado sobre a denúncia anônima, ele prontamente confessou que havia drogas na residência, autorizando a entrada da equipe policial na casa e apontando o local onde os entorpecentes estavam escondidos. Assim, embaixo da pia, em uma mala, encontraram 154 microtubos de cor amarela e 223 microtubos de cor branca, aparentando ser cocaína, 274 porções de maconha e 05 tabletes pequenos também de maconha, 120 recipientes pequenos de cor vermelha com substância aparentado ser maconha (tipo SKANK, o que é um tipo de droga mais potente e de maior valor comercial), 01 pedra grande em forma bruta de crack, uma balança de precisão, 02 celulares e ainda o valor de \$ 100,00. A casa tinha dois cômodos e a ré Monique saiu do quarto, vindo em direção à equipe. Informalmente, os

dois acusados informaram que as drogas tinham sido trazidas da cidade de Sorocaba, que Jackson era responsável pelo armazenamento e distribuição, que eram amasiados e que Monique tinha vindo com ele para esta cidade aderindo à conduta do réu. Na casa não tinha nenhum móvel, só um colchão com algumas peças de roupas, o que indicava que o local estava sendo usado exclusivamente para o fim do cometimento do crime de tráfico de entorpecentes. Disse que o denunciante também informou que poderia haver drogas em outro endereço perto dali, mas essa outra casa também estava fechada, para alugar. O proprietário morava nas proximidades e foi contatado, dizendo que havia sido procurado pelo casal para alugar o imóvel, mas o negócio não tinha dado certo. Assim, não ingressaram nesse outro imóvel.

No mesmo sentido as declarações prestadas perante a Autoridade Policial (fls. 09) pelo policial militar Rafael Pereira da Silva.

Anoto que os relatos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé. Os próprios réus disseram que nada tinham contra eles.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar suas palavras na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Confirmam-se alguns julgados:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

“Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas

alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido." (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO - j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar a alegação dos acusados em detrimento da palavra dos policiais: enquanto o interesse destes é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, o daqueles é eximir-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que os réus tinham em depósito, para entrega a terceiros, 377 "eppendorfs" contendo cocaína, 120 invólucros contendo "Cannabis sativa L.", 01 invólucro contendo "crack" e mais 279 invólucros contendo "Cannabis sativa L.", substâncias que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De fato, em que pesem as negativas de ambos, a prova revelou que a diligência policial foi precedida de informação anônima dando conta do armazenamento de drogas no local por um casal, para fins de tráfico.

Chegando ao imóvel, o réu permitiu o ingresso dos policiais e, conforme revelou a própria acusada, foi Jackson quem indicou a eles onde estavam escondidos os entorpecentes.

O policial hoje ouvido informou que, no imóvel, não havia móveis que normalmente guarnecem uma residência, mas somente um colchão com algumas peças de roupas.

Evidente, neste contexto, que os réus vieram para Piracicaba com o intuito de realizarem o tráfico de drogas e estavam usando o imóvel para esse fim.

Não há dúvidas do envolvimento de ambos no crime, restando claro que Monique aderiu à conduta do amásio no narcotráfico. Não é crível que ela desconhecesse a existência das drogas ali.

Quanto ao destino mercantil dos entorpecentes apreendidos, ficou evidenciado não só pelas circunstâncias da diligência policial, mas também em razão da grande quantidade de drogas, sua diversidade e pelo fato delas estarem embaladas em porções individuais, como geralmente são comercializadas (fotografias fls. 37/38). Além disso, junto com as drogas havia uma balança de precisão, objeto comumente utilizados por traficantes para fracionar as substâncias e expor a venda.

Outrossim, junto com as drogas foram encontrados R\$100,00, cuja origem lícita não foi comprovada, sendo obviamente, produto do tráfico.

Por fim, o réu Jackson afirmou que nem ele nem Monique eram usuários de drogas, o que confirma o destino mercantil dos entorpecentes.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"TÓXICO - TRÁFICO DE DROGAS - Insuficiência de provas - Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Mensagens que de whatsapp que não se mostraram o principal para configuração do crime. Apenas se somam aos depoimentos dos policiais. Utilizadas para confrontar o réu no momento da abordagem sobre a prática de tráfico de drogas, este admitiu e indicou onde estaria o restante das drogas. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para uso próprio.

Não acolhido. Ausência de comprovação de que fosse apenas usuário. De qualquer forma o ser usuário não espanca a condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo porque há necessidade de dinheiro para manutenção do vício, adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário vende para terceiros, para conseguir manter o próprio vício. Em regra, a paga é em espécie. Dosimetria da pena. Mantida sem alteração. Regime mantido. Não recomendável mais abrandamento. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.” (TJSP - Apelação Criminal 0000106-69.2018.8.26.0603 - 3ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro - J. 20/07/2020). g.n.

“MATERIALIDADE - Auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - Comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA - Depoimento de policiais que confirma a abordagem da ré e do menor, cujas características coincidiam com aquelas informadas em denúncia como sendo a dos traficantes, ocasião em que houve apreensão de drogas em poder do menor - Confirmação pelos policiais de que o adolescente afirmou que a ré trabalhava junto na traficância, na função de 'olheira' - Validade - Depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - Inocorrência no caso em tela. TRÁFICO - Destinação a terceiros - Quantidade incomum com a figura do usuário - Forma de acondicionamento das drogas, própria para a venda a varejo - Apreensão de dinheiro - Falta de condições econômicas para a ré possuir a droga para seu uso pessoal - Denúncia - De rigor a condenação da ré - Absolvição - Impossibilidade - Negado provimento ao apelo. CAUSA DE AUMENTO - Prática do delito que envolveu adolescente demonstrada pela prova oral - Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 configurada. PENA - Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal - natureza da droga de alto potencial lesivo - Manutenção - Presente a atenuante da menoridade - Redução da pena ao mínimo legal - Súmula 231 do STJ - Presente a causa de aumento relacionada com o envolvimento de adolescente - Exasperação da pena em 1/6 - Reconhecido o redutor na fração de 2/3 - Manutenção ante a inércia ministerial - Dedicção da ré à atividade criminosa - Passagem por ato infracional - Apreensão de considerável quantidade de droga - Profissionalização - Dedicção à atividade criminosa - Manutenção porque vedado a reformatio in pejus - Redução da pena - Impossibilidade - Improvimento ao apelo. REGIME - Fechado - Apreensão de elevada quantidade de droga - Natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo - Alta reprovabilidade e periculosidade - Ré que ostenta processo por ato infracional - O regime deve ser o necessário para dissuadi-los a retornar a delinquir (Beccaria) - Regime fechado - Necessidade - Improvimento ao apelo”. (TJSP - Apelação Criminal 1502824-11.2019.8.26.0544 - 6ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Lauro Mens de Mello - J. 16/07/2020) g.n.

Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação dos réus pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

Passo à individualização das penas.

Não obstante responda a outro processo por tráfico de drogas, o réu Jackson deve ser considerado primário e de bons antecedentes, pois ainda não sofreu condenação criminal definitiva por outros crimes (F.A. de fls. 58 /59 e certidão de fls. 55/57).

A ré Monique é primária e possui bons antecedentes (F.A. de fls. 62 e certidão de fls. 57 e 60/61).

As demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhes são desfavoráveis. Assim, fixo as penas-base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa para cada um.

Inexistem agravantes.

Reconheço a atenuante da menoridade relativa em relação ao réu Jackson, mas deixo de diminuir as penas, pois circunstâncias atenuantes não autorizam a redução aquém do mínimo legal.

Não há atenuantes em relação à ré Monique.

Inexistem causas aumento das penas.

Deixo de aplicar o redutor do parágrafo 4º, artigo 33 da Lei 11.343/06 para o réu Jackson, uma vez que os elementos dos autos indicam que não se tratava de traficante eventual.

De fato, conforme revelou a prova aqui trazida, ele veio de outra cidade para Piracicaba com o único intuito de realizar o narcotráfico, tanto que, para cá, trouxe na namorada e ambos estavam vivendo num imóvel onde sequer havia móveis compatíveis com uma moradia (havia só um colchão jogado no chão com algumas peças de roupas), o qual servia para o armazenamento das drogas que eram distribuídas. Some-se a isso o fato de os réus manterem em depósito expressiva quantidade de drogas e de diversos tipos, além de balança de precisão.

Também pesa contra ele a denúncia anônima que precedeu a diligência policial de que sua função era distribuir drogas nos bairros da cidade, o que, aliado às demais circunstâncias supraindicadas, indica claramente que se tratava de um gerente do tráfico.

Não bastasse, na data dos fatos, o réu estava no gozo de liberdade provisória que lhe foi concedida em outro processo de tráfico de entorpecentes, ocasião em que, como ele próprio admitiu, foram apreendidos doze quilos de maconha.

Tudo isso impede o reconhecimento do privilégio para o réu Jackson e, aliado às graves consequências do crime em questão, que fomenta a prática de vários outros delitos, destrói famílias, vidas e a saúde dos usuários, que dificilmente conseguem se livrar do vício, impõem a fixação de regime fechado para início do cumprimento da pena corporal e impede sua substituição por penas restritivas de direitos ou concessão de "sursis".

Eleição de regime diverso e aplicação de penas substitutivas da corporal, no caso concreto dos autos, impediriam que a pena cumprisse suas funções de prevenção e reprovação dos crimes, pois não fariam com que o réu sentisse as consequências de seus graves atos.

Há várias decisões de nossos Tribunais no sentido de que é possível a eleição do regime fechado, sem substituição por restritivas de direitos, no crime de tráfico de drogas se a natureza, a quantidade de drogas e as circunstâncias concretas do crime indicarem que se trata de agente de maior envergadura e não de pequeno e eventual traficante.

Confiram-se julgados do C. Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS (149 PEDRAS DE CRACK E UMA PORÇÃO DE MACONHA). ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 E ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo